

1525920-96.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

- Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico

ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato

da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525920-96.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525920-96.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência - 2308337/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 15145565 - 50º D.P. ITAIM
PAULISTA, 5905/2020 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO SOARES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 27/21

VISTOS.

MARCELO SOARES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, porque consta que no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 16h15min, durante estado de calamidade pública¹, na Rua Rafael Correia da Silva, 1, Itaim Paulista, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 51 (cinquenta e um) invólucros plásticos (ependorfs) contendo cocaína com peso líquido de 24,8 g (vinte e quatro gramas e oito decigramas) e 2 (duas) porções de tetrahidrocannabionol com peso líquido de 1,89g (um grama e oitenta e nove centigramas).

A denúncia foi recebida à fl. 69.

Defesa preliminar à fl. 113.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação e o réu, mesmo intimado, não compareceu ao ato, ocasião em que, foi decretada sua revelia.

Em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de uso, afastamento das agravantes, pena mínima, com regime mais brando, substituição e recurso em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, os argumentos da combativa defesa não arredaram os fortes indícios e provas diretas que derivaram contra o réu, em especial, pelos laudos periciais, testemunhas inquiridas e declaração do próprio acusado, que nada de exculpatório trouxe aos autos.

A materialidade do crime veio bem estampada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, dando conta dos 51 invólucros de cocaína, dos 02 invólucros de maconha, além de R\$ 26,55, localizados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o exame químico toxicológico de fls. 75, atestou que as substâncias localizadas em poder do acusado eram positivas para cocaína e tetrahydrocannabinol.

A autoria é igualmente incontestada.

Na fase inquisitiva o réu declarou que foi comprar um baseado na “loja” ali na linha do trem, que o vendedor se chama “Lucas”, e que assim que estava comprando esse tal de “lucas” pediu para segurar a sacola que iria comprar uma água, assim que ele saiu de perto, chegou dois indivíduos armados se apresentando como policiais, fls. 08.

No mais, não se preocupou em comparecer em Juízo a fim de colaborar com a boa instrução processual. Do contrário, tomou rumo ignorado demonstrando absoluto descaso para com a Justiça, visando eximir-se da responsabilidade penal que lhe era inerente.

No entanto, as justificativas inquisitivas do réu, secundadas pelos argumentos defensivos, não encontraram respaldo nas demais provas dos autos motivo pelo qual, não convenceram.

Não se pode crer que o acusado estivesse no local, de proibido acesso para população, quando fosse, do nada, abordado pelos agentes e acusado da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse ele efetiva participação nos fatos.

Até porque, não há como se acreditar que o réu corresse o risco permanecer perambulando pelas ruas da cidade com tamanha quantidade de drogas apenas para seu uso. Tal circunstância somente é suportada pelos traficantes, que no afã de obterem lucro com a venda da droga, desprezam a periculosidade de suas condutas.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, as circunstâncias dos autos, tais como, a grande quantidade do tipo de droga encontrada, a forma como estavam acondicionadas, em papéis distintos, prontos para a venda individual, somado ao local em que o réu foi abordado, a fala firme dos agentes, não deixam dúvidas acerca da traficância. E assim é porque os agentes ferroviários responsáveis pela prisão do acusado, Elias Cordeiro dos Santos e Jefferson Amarante de Souza, ouvidos nos autos, relataram de forma firme e segura, em uma só voz que eu e meu amigo fomos atender uma outra ocorrência, e em nosso deslocamento, nos deparamos com ao réu na via, sentado debaixo de uma passarela, que é conhecido ponto de drogas. Optamos pela abordagem, e em revista, encontramos uma bolsinha com as drogas, celular e dinheiro. Nós estávamos na via, e encontramos o réu sentado em um banco rasgado. No interior do banco é que estava a bolsinha com as drogas. Nós optamos pela abordagem dele, porque ele estava em um local em que é muito comum ocorrer a prática do tráfico, é um local em que é proibido o acesso a populares, então os traficantes se escondem ali, quando a polícia se aproxima.

Os agentes narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde patrulhamento de rotina com a intenção de atendimento de outra ocorrência, a atitude suspeita do réu em local conhecido como

ponto de tráfico, o encontro das drogas dentro da sacola que o réu portava, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Com efeito, há muito tempo já se encontra superada a sustentação de ser insuficiente a prova policial.

Neste sentido: "Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Tóxico. Depoimento prestado por policial. Prova firme e coerente. Apreensão em fiscalização de Trânsito e de rotina. Circunstância que justifica o não arrolamento de testemunha alheia ao quadro policial. Recurso não provido". (Apelação criminal. 126.697-3, rel. Des. Álvaro Cury. RJTJESP n. 138/451).

De outra banda, ao contrário do que argumentou a esforçada defesa, os depoimentos dos agentes ferroviários foram tranquilos, harmoniosos e revelaram sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova.

Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e as eventuais discrepâncias alegadas pela culta defesa do réu, em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Da mesma maneira, não há nos autos qualquer indício que demonstre existência de inimizade anterior, que possa justificar eventual intenção em prejudicar o acusado, ou mesmo incriminá-lo falsamente, pelo que, as palavras das testemunhas merecem credibilidade.

No mais, o fato de se tratarem de agentes ferroviários e não policiais, em nada abala a tese acusatória, até porque, qualquer do povo pode prender em flagrante, ao presenciar a ocorrência de um crime.

Em que pesem os argumentos da nobre Defensoria Pública alegando em síntese que o réu é usuário e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, a forma como estavam embaladas, de forma individualizada, prontas para venda, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

No mais, nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia ou mesmo possibilitar a desclassificação para uso próprio. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição ou desclassificação pretendida pela defesa.

Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Em arremate, não há que se falar na incidência da agravante referente à calamidade pública, tendo em vista que a pandemia que assola a população mundial, em nada afeta os fatos ora tratados nestes autos. Observo que o crime não sofre qualquer influência pela atual situação pandêmica, ao menos nada há nos autos que comprove o contrário. Nesta esteira de raciocínio, a agravante postulada pelo representante do ministério público há que ser afastada.

Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário, menor de 21 anos de idade, e não ostenta antecedentes criminais, pelo que, fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem qualquer antecedentes, é jovem e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa. Assim, considerando-se a capacidade lesiva de uma das drogas em questão, tratando-se de cocaína, reduzo a pena base em 1/2, perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar MARCELO SOARES SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, sem qualquer mácula em sua vida, foi solto no curso do processo, de maneira que faze-lo retornar aos sistemas carcerários mostra-se medida extrema.

De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantém repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever:

“Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum).”

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente

apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.
Custas na forma da lei.
P.R.I.C.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
(Juíza de Direito)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA